

1501052-59.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... por ato infracional equiparado ao tráfico. Teve cerca de três passagens por tráfico enquanto adolescente. Cumpriu duas internações e três provisórias. Não teve liberdade assistida. Os policiais chegaram a sua residência por volta das 17:00 horas. Existe um terreno baldio em frente à sua casa, local onde os policiais foram com o cão farejador no dia dos fatos. Não observou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501052-59.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501052-59.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO BRAZOLOTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

V I S T O S.

CLÁUDIO BRAZOLOTO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20 de julho de 2021, por volta das 16:30 horas, na Rua Professora Judith Marchareth, na altura do nº 1.005, no Bairro Chácaras TV, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, trazia consigo, para comercialização ilícita, duas porções de "Cannabis sativa-L" (maconha) (princípio ativo: delta-9-THC), droga capaz de produzir dependência e, ainda, nas mesmas condições de tempo, no quintal do imóvel situado na Rua Professora Judith Marchareth, nº 1.005, bem como no terreno baldio situado à frente do mencionado imóvel, no Bairro Chácaras TV, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito, para comercialização ilícita, trinta e oito porções e um tijolo menor de "Cannabis sativa-L" (maconha) "princípio ativo: delta-9-THC", droga capaz de produzir dependência, e 1.288,92 gramas de "Cannabis sativa-L" (maconha) (princípio ativo

delta-9-THC), droga capaz de produzir dependência, distribuída em duas porções (tijolos). As quarenta porções de "Cannabis sativa-L" (maconha) (princípio ativo delta-9-THC) totalizaram 285,68 gramas.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar a fls. 181/182. A denúncia foi recebida a fls. 187/190. No decorrer da instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, após, interrogado o acusado (fls. 229/232, 268 e 298/301).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça pediu a procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 305/311), ao passo que a Defesa arguiu preliminar de nulidade processual, aduzindo a falta de intimação pessoal do Defensor Público da data da realização da audiência para oitiva da testemunha de defesa, a atuação deficiente da advogada nomeada para o ato e a ausência de intimação e de comparecimento do réu em tal audiência. No mérito, requereu a absolvição, sustentando, em síntese, que a prova é precária. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo, a imposição do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 314/346).

O Dr. Promotor de Justiça se manifestou sobre a preliminar de nulidade processual a fls. 352/355.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, passo à análise da preliminar arguida pela Defesa.

A alegação de nulidade dos atos processuais desencadeados a partir da audiência para oitiva da testemunha André Luis Trindade Solis não prospera. Isso porque, não restou demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa do réu em relação a nenhum dos três fundamentos articulados ---falta de intimação pessoal do Dr. Defensor Público, defesa deficiente na audiência deprecada e ausência do réu durante a oitiva daquela testemunha---. De fato, a ausência de intimação pessoal do Dr. Defensor Público foi suprida pela nomeação, pelo Juízo deprecado, de advogada ad hoc para realização do ato, que dele participou, garantindo ao réu, assim, o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório. Ademais, como bem observado pelo Dr. Promotor de Justiça a fls. 352/355, a Defensoria Pública foi devidamente intimada da expedição da carta precatória (fls. 229/231 e 243), sendo desnecessária sua intimação da data da audiência no juízo deprecado, nos termos da Súmula nº 273 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. No que tange ao argumento genérico de que a defesa naquele ato teria sido deficiente pela ausência de perguntas formuladas pela advogada nomeada à testemunha, ressalto que a opção técnica adotada pela causídica, isoladamente, não pode ser confundida com a falta de defesa, sobretudo porque, no caso concreto, como adiante se verá, o depoimento prestado pela referida testemunha durante a fase policial em nada favoreceu o acusado.

Em análise a situações semelhantes, assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça:

"Sentença - Desnecessidade de análise expressa das teses - Precedentes - Nulidade - Inocorrência - Preliminar rejeitada; Sentença - Falta de intimação pessoal da Defensoria Pública da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha policial - Ausência de prejuízo, uma vez que foi nomeado Defensor ad hoc Preliminar rejeitada; (...) Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal nº 0060371-52.2015.8.26.0050; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Des. Relator: Alexandre Almeida; Data de Julgamento: 02/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019).

"APELAÇÃO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Processada e levada à mesa para julgamento a apelação interposta, resta prejudicado, a esta altura, o pedido de concessão do direito de apelar em liberdade. NULIDADE. RÉU QUE ESTEVE INDEFESO E REVELIA QUE TERIA SIDO DECRETADA EM PREJUÍZO À DEFESA. 1. Assevera o apelante que deficiente a defesa dativa, que nada reperguntou à vítima e às testemunhas durante a instrução, bem como em sede de alegações finais, concordou com a condenação e pleiteou a fixação da pena no mínimo legal. Sem razão. Tendo o réu deixado de comparecer para interrogatório tanto na delegacia, porque foragido, como em Juízo, pois, intimado, preferiu não comparecer, tornando-se revel e com isso abrindo mão de dar sua versão dos fatos, razoável a posição do defensor, que buscou a fixação da menor pena possível, máxime porque o conjunto probatório confirmou a assunção de culpa do sentenciado. Estratégia de defesa que não pode ser considerada falta dela, até porque em consonância com a postura do patrocinado. (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 0001764-40.2016.8.26.0655; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Várzea Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019).

Por fim, sem a demonstração de efetivo prejuízo, a ausência réu na audiência para inquirição da testemunha também não implica na nulidade processual arguida pela Defesa, conforme precedente a seguir transcrito:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio tentado - Artigo 157, §3º, in fine, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal - PRELIMINAR - Nulidade por cerceamento de defesa em razão do não comparecimento do réu para oitiva da vítima realizada fora da Comarca - Inexiste nulidade na ausência de requisição de réu preso para assistir à prova coligida por precatória, vez que não sendo possível ou conveniente o seu transporte para a Comarca deprecada, a prova é assistida por seu defensor, ou, se este não comparecer, pelo que lhe for nomeado em substituição - Colendo Superior Tribunal de Justiça - Precedentes Rejeição (...) RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação nº 0003943-84.2013.8.26.0223; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 1ª Vara Criminal; Des. Relator: Silmar Fernandes; Data de Julgamento: 17/04/2015; Data de Registro: 22/04/2015).

Afasta a preliminar, no mérito a ação penal é procedente.

A materialidade do crime veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, laudos de constatação prévia de fls. 22/23 e exames químicos toxicológicos encartados a fls. 116/121, que resultaram positivos para maconha.

E a responsabilidade criminal do acusado é indubitosa.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime de tráfico. Disse que não teve nada a ver porque tinha acabado de tomar banho, saiu na porta da sala de sua casa e então apareceu um motociclista que lhe perguntou se tinha ferro-velho. Respondeu ao indivíduo que o seu pai não estava mais comprando e que apenas o vizinho o fazia. Foi abordado junto com o motociclista. Os policiais passaram na frente, ingressaram na residência e encontraram consigo somente a quantia de R\$ 10,00 em dinheiro, que conseguiu pegando ferro-velho na rua e que estava em seu bolso. Acredita que nada foi localizado com o motociclista. Afirmou para os policiais que não havia nada de ilícito na casa e, em busca no local, eles não encontraram nada. Foi levado para a DIG, onde os policiais lhe disseram que tinham localizado algumas coisas. Os policiais não lhe mostraram droga. Foi levado cão farejador a sua residência. Não conhecia o motociclista nem os policiais. Ajudava seu pai com o ferro-velho. Residia na casa com seus pais e irmãos. Já foi processado enquanto menor, cumprindo medida de internação na Fundação Casa por ato infracional equiparado ao tráfico. Teve cerca de três passagens por tráfico enquanto adolescente. Cumpriu duas internações e três provisórias. Não teve liberdade assistida. Os policiais chegaram a sua residência por volta das 17:00

horas. Existe um terreno baldio em frente à sua casa, local onde os policiais foram com o cão farejador no dia dos fatos. Não observou essa diligência. Não vendeu drogas para o motociclista e não ouviu o que ele disse aos policiais durante a abordagem. Não viu os policiais encontrarem droga após a chegada do cão farejador.

Ocorre que versão apresentada pelo réu, no sentido de que a droga apreendida não lhe pertencia, não convence, vez que restou isolada no contexto probatório, que o compromete.

De fato, ouvido em Juízo, o policial Wagner Antonio da Silva disse que estavam em patrulhamento de ROCAM pelo Bairro Chácara TV quando adentraram na Rua Judith Marchareth e, em frente ao numeral 05, onde funciona um ferro-velho, local conhecido como ponto de venda de entorpecente, visualizaram um motociclista em contato com outra pessoa e entregando algo para ela. Ao se aproximarem, o réu, que foi identificado posteriormente, dispensou duas porções de maconha no chão. Abordaram os dois separadamente e os indagaram sobre o que estavam fazendo ali. A testemunha André, que era o motociclista, relatou que era viciado e que estava ali comprando entorpecente, o que não fazia pela primeira vez, bem como que tinha passado uma nota de R\$ 10,00 para o vendedor. Questionado, o acusado permaneceu calado, mas localizaram com ele a quantia de R\$ 10,00 em dinheiro e as duas porções que o avistaram dispensando. O réu tentou fugir, mas não conseguiu porque já estavam próximos e o abordaram no quintal da frente da residência, cujo portão estava aberto. Como tinham várias informações, solicitaram apoio da Força Tática e do Canil. Realizaram vistoria no quintal da casa com o cão Ragnar e, nos fundos, sobre um pallet de madeira, localizaram trinta e oito porções de maconha idênticas àquelas dispensas pelo acusado em frente à residência, além de meio tijolo de maconha embalado em fita vermelha. Prosseguiram a vistoria e nada mais foi localizado na casa, porém, no terreno da frente, onde o réu escondia entorpecentes segundo informações que tinham, encontraram mais dois tijolos de maconha embalados em fita vermelha, idênticos aos localizados no quintal da casa do acusado, e vários saquinhos novos e vazios do tipo zip-lock, geralmente utilizados para acondicionamento de entorpecentes como maconha e cocaína. Havia trinta e três pacotinhos e cada um deles continha cem embalagens zip-lock. Já conhecia o réu e o abordou anteriormente diversas vezes. Não se recorda se o acusado já teve envolvimento com tráfico de drogas, mas possuíam informações da prática de tráfico no local, inclusive o genitor dele foi preso algum tempo atrás. O réu não lhes relatou nada sobre a droga encontrada. Apenas a genitora do acusado estava na residência. No quintal, junto com as trinta e oito porções de entorpecente e o meio tijolo de maconha, também apreenderam um rolo de plástico filme. O pedaço de maconha encontrado no quintal pesou aproximadamente 250 gramas e, com mais os outros dois tijolos, totalizaram cerca de 1.290 gramas. O imóvel é a residência do réu e ali também moravam os pais e o irmão dele, Cleiton. A casa é guarneçada por muro e, no lugar do portão, existem tapumes de madeira. O terreno da frente onde o restante da droga foi localizado é aberto. Não visualizaram o acusado mexendo neste terreno, mas possuíam informações de que ele guardava entorpecente ali também. A droga localizada no terreno era idêntica àquela encontrada na residência. As informações eram relacionadas à pessoa do réu e ao local dos fatos.

E não há porque se colocar em dúvida a versão do policial, porque como qualquer outra testemunha ele presta compromisso de dizer a verdade, e não viria a Juízo apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizou. Note-se que não há prova nos autos de qualquer desavença anterior entre o policial e o réu, de forma que seu depoimento merece credibilidade, pois não teria qualquer motivo para acusar injustamente um inocente. Enfim, não se pode desconsiderar uma prova por mera presunção, sem prova de suspeita ou má-fé.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“Por sua vez, o art. 207 estabelece quais as pessoas proibidas de depor, o que se

dá em razão de função, ministério, ofício ou profissão, não estabelecendo qualquer restrição aos agentes que efetuem a prisão em flagrante no sentido de servirem como testemunhas. Assim, desde que tais depoimentos não se tornem suspeitos ou indignos de fé, têm plena validade em face da lei (TJSP - AC- Rel. Hoepfner Dutra - RT 416/96).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/2756).

No mais, André Luis Trindade Solis, ouvido em Juízo, nada declarou, porém, inquirido na fase policial, disse que é usuário de maconha e estava no local para adquirir drogas para seu consumo. Tinha acabado de chegar ao local, mas com a aproximação da viatura o acusado saiu correndo para o interior do imóvel. Ainda não tinha negociado a compra da droga. Já comprou droga no local dos fatos. Reside em Guararapes e trabalha como eletricitista. Faz uso de maconha desde adolescente e nunca foi preso ou processado.

Assim, o conjunto probatório é farto na demonstração de que toda a droga apreendida realmente pertencia ao acusado.

E o destino do entorpecente apreendido em poder do réu é manifesto, vez que tinha em depósito e trazia consigo, em um local conhecido como pronto de venda de drogas, uma enorme quantidade de drogas, ou seja, 1.574,60 gramas de maconha. A quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida ---dois tijolos de maconha pesando 1.288,92 gramas, quarenta porções, prontas para imediata comercialização, e mais um tijolo menor da mesma substância, totalizando 285,68 gramas da droga---, os petrechos apreendidos ----trinta e três sacos plásticos contendo cada um deles aproximadamente cem unidades de embalagens do tipo zip-lock, próprios para o acondicionamento de maconha---, além da apreensão da quantia de R\$ 10,00 em dinheiro, sem comprovação de origem lícita ---conforme relatado pelo policial Wagner, o réu e a testemunha André foram indagados separadamente e o segundo disse ao miliciano que estava ali para comprar droga e que tinha entregue R\$ 10,00 para o acusado, que tinha em seu bolso esta exata quantia no momento da abordagem---, ou seja, o produto do crime, demonstram a finalidade do tráfico de entorpecentes.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a finalidade de tráfico de entorpecentes é evidente.

Verifica-se, portanto, que a prova acusatória forma um todo coeso e concorde, perfazendo a necessária certeza para a prolação do decreto condenatório, afastando-se toda e qualquer tese absolutória.

Assim, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, em face da sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

O réu não ostenta antecedentes criminais. Atendendo, por outro lado, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, notadamente a elevada quantidade de droga apreendida, fixo a pena base acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena ao patamar mínimo legal.

Na terceira fase de dosimetria penal, o acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Isso porque o réu trazia consigo e tinha em depósito uma enorme quantidade de maconha e, embora primário, enquanto adolescente cumpriu medidas socioeducativas de internação e de liberdade assistida pela prática de três atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de entorpecentes (fls. 160/161, 164/166 e 172/174). Diante de tais circunstâncias e considerando que o acusado não possui emprego lícito comprovado nos autos, resta claro que ele não se trata de mero traficante ocasional, mas sim que, desde a adolescência, se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico seu meio de vida e fonte de renda. Assim, o réu não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício ---“desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa---. Neste sentido: “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. SITUAÇÃO IDÔNEA A SER VALORADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE DROGA. USO NA PRIMEIRA FASE E NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack. IV - De mais a mais, o Tribunal de origem afirmou que o paciente "assume funções de chefia e direção em organização criminosa. Acrescente-se que, conforme documento de fl. 52, o réu apresenta inúmeras passagens pela Vara da Infância, fazendo do crime o seu meio de vida desde a adolescência". Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes" (AgRg no HC n. 588.716/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28/08/2020). V - Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. VI - Ainda, insta consignar que é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.255.180/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/02/2013; HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017; AgRg no REsp n. 1.779.825/RO, Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/05/2019. VII - Regime inicial. A quantidade e a natureza do entorpecente - 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack - foram utilizadas como fundamentos a

ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 641.285/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). "TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos guardas civis municipais em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada - Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (16 porções de 'maconha', com peso líquido de 18,11 gramas), além de dinheiro e celular - Crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino e envolvendo adolescentes - Condenação eskorreita. PENAS E REGIMES PRISIONAIS - Bases nos mínimos. Natureza e quantidade de droga que, embora relevante, não justificam a exasperação - Menoridade relativa e agravante do artigo 61, II, "j", do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública). Compensação - Exclusão do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Réu que ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, três delas por ato infracional equiparado ao tráfico. Causas de aumento do artigo 40, III e VI, da Lei de Drogas. Acréscimo de 1/5 - Regime inicial fechado - Apelo ministerial provido para afastar a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, majorar as penas e fixar o regime inicial fechado. (TJSP; Apelação Criminal nº 1501321-34.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Des. Relator: Gilberto Ferreira da Cruz; Data de Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021). "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEFESA PLEITEIA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E A MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA QUE SEJA ELEVADA A PENA-BASE, AFASTADA A INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006, FIXADO O REGIME FECHADO E CASSADA A SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS - COM INTEIRA RAZÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO - PENAS ALTERADAS - RÉU PRIMÁRIO, MAS COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DEDICAÇÃO AO NEFASTO COMÉRCIO DEMONSTRADA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA - IMPOSSIBILIDADE DE PERMUTA E DE RIGOR O REGIME FECHADO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE EMPREITADA CRIMINOSA - A MULTA NÃO PODE SER REDUZIDA, POIS JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL - EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO -RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal nº 1500927-84.2019.8.26.0628; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Des. Relator: Euvaldo Chaib; Data de Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020).

Portanto, ante a ausência de circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena aplicada.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra CLÁUDIO BRAZOLOTO, qualificado nos autos, e o condeno ao cumprimento de cinco anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O regime para o cumprimento de pena é o inicial fechado, único recomendável diante da latente e concreta gravidade do crime (o réu se dedica ao tráfico de drogas, não se enquadrando o delito em questão na figura do chamado "tráfico privilegiado", como já visto), fomentador de tantas outras práticas ilícitas, restando evidentemente prejudicada a aplicação da Lei nº 9.714/98, mesmo porque os objetivos do legislador com a promulgação desta Lei demonstram que ela afeta apenas aos crimes menos graves, distanciam-se em muito da hedionda mercancia.

Demais disso, ainda que alguns requisitos do artigo 44, do Código Penal fossem

favoráveis ao réu (o que não é o caso, vez que a pena aplicada é superior a quatro anos de reclusão), não estaria configurado o previsto pelo inciso III, in fine, do mencionado dispositivo legal, ou seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". O traficante é um grande responsável direto pela onda de violência que avassala o país. A insuficiência da substituição em tela para a repressão e prevenção do tráfico ilícito de entorpecentes no caso concreto é patente, por conseguinte.

Considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o regime de pena imposto, e mormente o fato de ter sido preso em flagrante delito e encontrando-se detido até hoje, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu, apesar de primário e de bons antecedentes, respondeu a ação penal, quando havia apenas o "fumus boni iuris", preso, após a prolação de sentença, surge a certeza que exclui a possibilidade do recurso em liberdade" (RJDTCRIM 13/181). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Logo, o réu não poderá recorrer em liberdade, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra, mesmo porque continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como já exposto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e nas que a mantiveram.

Ressalto que eventual detração penal (art. 387, § 2º do CPP) deve ser postulada, oportunamente, ao juízo das execuções criminais competente, o qual possui condições de aferir a presença dos requisitos legais, especialmente os de natureza subjetiva.

Neste sentido: "Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar. Nulidade das provas obtidas mediante atuação da guarda municipal. Prisão em flagrante. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas corretas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade, nocividade e diversidade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido" (TJSP; ApelaçãoCriminal1500272-11.2021.8.26.0542; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador:8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022).

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, declaro perdidos em favor da União os valores apreendidos em poder do acusado, descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, pois se tratam de produto do crime.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da Lei.

P. I.C.

Araçatuba, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA